

1501788-14.2020.8.26.0603

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

Comarca: Birigui

Foro: Foro de Birigui

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/01/2022

... princípio in dubio pro reo, referente ao tráfico de drogas (fls. 310/324).

Por fim, a defesa do réu Lucas requereu a absolvição do acusado quanto ao crime de resistência, por insuficiência de provas. Referente ao tráfico de drogas, não há provas de que iria comercializá-las. Pleiteou a realização de exame de dependência toxicológica. Em caso de condenação, pediu a fixação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Birigui

Foro de Birigui

1ª Vara Criminal

Rua Faustino Segura nº 214, Birigui-SP - cep 16200-370

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501788-14.2020.8.26.0603 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501788-14.2020.8.26.0603

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência -

2316148/2020 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 15291744 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI,

3982/20/309 - DEL.POL.PLANTÃO BIRIGUI, 2316148 - 02º D.P. BIRIGUI, 3982/20/309 -

02º D.P. BIRIGUI

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS GARCEZ URIAS e outro

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ADRIANO PINTO DE OLIVEIRA

S E N T E N Ç A

Processo nº. 1501788-14.2020.8.26.0603 (Controle 28/2021).

VISTOS.

MÁRCIO DOS SANTOS MOTA e LUCAS GARCEZ URIAS, vulgo "Luquinha", qualificados nos autos, foram presos em flagrante delito, denunciados e viram-se processados como

incursos no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e artigo 329, caput, na forma do artigo 69, caput, do Código Penal, porque, no dia 18 de dezembro de 2020, por volta das 19h30min, na Rodovia Gabriel Melhado (SP 461), altura do KM 04, cidade e Comarca de Birigui, agindo em coautoria, traziam consigo 01 (um) tijolo de maconha, pesando 1.006,4 gramas, substância entorpecente, que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo de constatação provisória de fl. 17.

Consta, também, que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, MÁRCIO DOS SANTOS MOTA e LUCAS GARCEZ URIAS, qualificados nos autos, opuseram-se à execução de ato legal, mediante violência a funcionário competente para executá-lo.

Apesar de mantido preso na audiência de custódia (fls. 66/70), o acusado Lucas foi solto mediante decisão proferida em sede de habeas corpus, autorizando-o a responder ao processo em liberdade (fl. 177), sobrevivendo expedição de alvará de soltura.

Recebida a denúncia em 12 de janeiro de 2021 (fls. 106/107), os acusados foram regularmente citados (fls. 174/176) e apresentaram suas defesas escritas às fls. 109/127 e 195/197.

Na instrução, foram colhidos os depoimentos de 02 (duas) testemunhas arroladas pela acusação e pelo réu Lucas e 02 (duas) testemunhas arroladas pela defesa dos réus, sobrevivendo, ao final, os interrogatórios dos réus (fls. 284/285).

Em alegações finais, o Ministério Público pleiteou a parcial procedência da ação, condenando-se os acusados pelo crime previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 e absolvendo-os quanto ao delito do artigo 329, caput, do Código Penal (fls. 301/307).

A defesa do réu Márcio, por sua vez, sustentou que a denúncia é inepta. Pediu a absolvição do réu, alegando insuficiência de provas, aplicando-se o princípio in dubio pro reo, referente ao tráfico de drogas (fls. 310/324).

Por fim, a defesa do réu Lucas requereu a absolvição do acusado quanto ao crime de resistência, por insuficiência de provas. Referente ao tráfico de drogas, não há provas de que iria comercializá-las. Pleiteou a realização de exame de dependência toxicológica. Em caso de condenação, pediu a fixação da pena no mínimo legal e o reconhecimento da confissão (fls. 325/329).

É o relatório.

Decido.

Trata-se de ação penal pública incondicionada que se destina a apurar a responsabilidade dos denunciados pela prática de condutas que, em tese, estariam a configurar os delitos de tráfico ilícito de drogas e resistência (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06 e art. 329, caput, do Código Penal).

De início, não é caso de realização de exame de dependência toxicológica no acusado Lucas.

Primeiro, porque o acusado, em sua resposta escrita, em nenhum momento requereu a realização do exame, fazendo-o somente durante a audiência de instrução e reiterando o pedido em alegações finais.

Segundo, porque, apesar de o réu ter afirmado ser usuário de droga, confessou na delegacia e para os policiais que também vendia entorpecente, demonstrando, em seu interrogatório judicial, plena capacidade de raciocínio e boa memória auditiva, respondendo a todas as perguntas dentro da normalidade, não deixando qualquer suspeita sobre sua capacidade de compreensão da ilicitude do fato e de sua autodeterminação.

O exame de dependência toxicológica só é indispensável a fim de aferir a capacidade mental do acusado para entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Não há nos autos, entretanto, qualquer indício de que o réu necessitasse desta aferição. Ademais, conforme inteligência do artigo 184 do CPP, o exame toxicológico pode ser negado, se for dispensável ou desnecessário ao esclarecimento da verdade, como é o caso, em que o réu acabou confessando, na fase policial, a prática do tráfico de drogas.

Assim, ainda que se admita que o réu seja usuário de droga, a simples condição de usuário não é o bastante a justificar a oportunidade do exame de dependência química, pois sua efetiva necessidade emana da existência de indicativos fáticos

geradores de dúvida acerca da normalidade psíquica do acusado, em decorrência do vício, impossibilitando-a de entender a ilicitude do fato ou de determinar-se de acordo com ele. Evidenciada sua dispensabilidade, a não feitura do referido exame deixa de caracterizar cerceamento de defesa.

Em outras palavras, somente quando o conjunto probatório autorizar suspeita razoável de que o réu é dependente, com características próprias de perturbação mental consequente ao uso de drogas, é que justifica a realização de exame de dependência toxicológica, pois sua necessidade não decorre de singela afirmação do agente de que é consumidor de tóxico ou de injustificada pretensão da defesa.

Ademais, não há que se falar, também, em inépcia da denúncia, como alegado pela defesa do réu Márcio. A denúncia contém a individuação da conduta dos acusados, o que é suficiente para o recebimento da denúncia e o exercício da ampla defesa. Tanto é assim que os acusados apresentaram a sua resposta escrita e suas alegações finais a contento, nas quais alegaram inúmeras matérias, demonstrando, de uma vez, que as defesas foram amplamente exercidas.

Desta forma, a denúncia preencheu os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, motivo pelo qual foi regularmente recebida por este Juízo e possibilitou a ampla defesa dos réus, não podendo ser considerada inepta.

No mérito, a ação penal é parcialmente procedente.

Ao término da instrução criminal, e após um atento exame das provas existentes nos autos, não há como se deixar de reconhecer que a materialidade e a autoria dos fatos narrados na denúncia ficaram parcialmente comprovadas.

Considerando que a presente ação penal apura mais de um delito, envolvendo dois réus, passo a analisar separadamente os fatos, para sua melhor elucidação.

Tráfico de Drogas

A autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de drogas restaram comprovadas para ambos os acusados.

Nesse sentido, temos: o auto de prisão em flagrante (fl. 01); o boletim de ocorrência (fls. 04/06); as notas de culpa (fls. 08 e 10); o auto de exibição e apreensão (fls. 12/13); o auto de constatação prévia (fl. 17); o relatório final (fls. 94/98); o laudo pericial (fls. 295/297); os depoimentos das testemunhas; a confissão apresentada pelo acusado Lucas, na fase policial, e sua posterior retratação em juízo, bem como as indigestas e contraditórias negativas apresentadas pelo réu Márcio, em ambas as fases da persecução penal.

O acusado Lucas, na delegacia, disse que conduzia a motocicleta, tendo como garupa Márcio. Confirmou que adquiriu a droga apreendida, cerca de 1 kg de maconha. Realizou a compra em Birigui, por R\$ 1.400,00 e venderia cada porção, por R\$ 10,00, na cidade de Piacatu. Afirmou que Márcio não sabia da existência da droga e, quando avistou a viatura policial, empreendeu fuga, momento em que arremessou a droga que trazia consigo. Por fim, disse que as lesões que apresenta são oriundas da fuga e não de agressões dos policiais (fl. 09).

A confissão livre e espontânea prestada no processo serve como importante elemento de convicção para evidenciar a autoria e amparar a condenação, quando encontrar sustentação nos demais elementos de convicção produzidos.

Em juízo, todavia, como sói de acontecer, o réu alterou parcialmente a versão, passando a negar a prática do tráfico, afirmando que a droga era para uso próprio, e que Márcio apenas o acompanhou na motocicleta. Disse que apresentou a versão na delegacia, porque foi pressionado e coagido pelos policiais. Detalhou que estava regressando para Piacatu, quando viu Márcio no trevo e ele pediu carona. Quando viu os policiais, empreendeu fuga e Márcio começou correr junto e perguntar, foi quando falou que estava com droga. Pediu a realização de exame toxicológico. O dinheiro apreendido (R\$ 30,00) era proveniente do seu trabalho na roça. Negou a ocorrência de uma abordagem anterior. Confirmou que pagou R\$ 1.400,00 na droga e o dinheiro era seu. Ganha R\$ 90,00 por dia e fuma 04 cigarros por dia, gastando R\$ 10,00 por dia (fls. 284/285).

Como se viu, o acusado Lucas, apesar de ter confessado a prática do tráfico na fase

policial, em juízo, retratou-se e passou a negar a autoria do crime.

Todavia, como se verá adiante, a prova oral produzida é robusta e só vem corroborar a confissão extrajudicial do acusado, caindo em descrédito a retratação judicial por ele oferecida. É que a simples retratação em juízo, sem ressonância nos autos, não invalida confissão feita perante a autoridade policial.

Por sua vez, o réu Márcio, na fase extrajudicial, disse que estava na garupa da motocicleta conduzida por Lucas, mas não tinha conhecimento de que ele trazia consigo os entorpecentes. Empreenderam fuga e neste momento soube que Lucas estava com drogas. A droga apreendida é de Lucas. Afirmou que foi agredido pelos policiais (fl. 07).

Em juízo, disse que o Lucas o chamou para acompanhá-lo em uma manutenção na motocicleta e, na primeira abordagem, os policiais encontraram apenas R\$ 1.400,00. Foram liberados e Lucas foi realizar a manutenção da moto. Estavam retornando e Lucas dispensou a droga, mas nada sabia. Afirmou que o policial deu uma “pesada” no seu peito (fls. 284/285).

Como se vê, os acusados apresentaram contradições entre si. Lucas disse que não houve uma primeira abordagem; já Márcio afirmou que foram abordados e liberados uma vez e depois foram abordados novamente. Ademais, o réu Lucas afirmou, também, que estava retornando para Piacatu, quando deu carona para Márcio; este, por sua vez, disse que acompanhou Lucas, que veio para Birigui fazer uma manutenção na sua motocicleta.

Diante dessas contradições, relacionadas a pontos de fundamental relevância para o deslinde da causa, não há como se dar credibilidade às versões apresentadas pelos acusados, que restaram isoladas e contraditórias, se cotejadas às demais provas coligidas sob o crivo do contraditório, que apresentaram grau de idoneidade bem mais elevado, como se verá doravante, não passando de mero expediente utilizado na tentativa de se furtarem da responsabilização penal por conduta efetivamente praticada.

Com efeito, as testemunhas de acusação Luiz Henrique Nogueira e Fernando Rodrigo Marchiolli, policiais militares, ouvidas em ambas as fases, relataram que estavam em deslocamento para a cidade de Piacatu, quando avistaram os dois acusados na motocicleta. Eles empreenderam fuga. Ao conseguirem abordar o corréu Lucas, encontraram um tijolo de maconha e R\$ 30,00 em dinheiro. Lucas confessou que ele e Márcio haviam adquirido a droga em Birigui, pagando R\$ 1.400,00, e venderiam na cidade de Piacatu. Foi necessário uso de força física para deter os acusados. Em juízo, acrescentaram que realizaram uma primeira abordagem, no bairro Colinas, e Márcio estava com R\$ 1.400,00, que ele alegou, naquele momento, que era oriundo da venda de uma motocicleta (fls. 02, 03 e 284/285).

Como se vê, os policiais confirmaram que os réus confessaram a prática criminosa. Os relatos dos policiais foram uníssonos e evidenciam que os réus incidiram na prática do crime de tráfico ilícito de entorpecente.

O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

Tal depoimento somente não terá valor quando se evidenciar o interesse do servidor na investigação penal, e quando suas declarações não encontrarem suporte em outros elementos probatórios idôneos.

Neste ponto, não prospera a alegação dos acusados de que foram pressionados, coagidos e agredidos pelos policiais, já que tal alegação não foi amparada por qualquer prova produzida pelos réus.

Sabe-se que os cidadãos bem intencionados não admitem mais conviver com repressões passadas que foram sepultadas pelo Estado Democrático de Direito instalado em nosso País na atualidade.

As afirmações dos acusados acerca da pressão ou agressões feitas pelos policiais

são inconsistentes, porquanto, se efetivamente agredidos, insurgiriam-se de pronto e tomariam, logo em seguida, as medidas necessárias para que os policiais fossem punidos, mas nada disso se vê nos autos.

Importante salientar que não existe qualquer circunstância que justificasse o interesse dos policiais em prejudicá-los, sobretudo porque não apontaram nada que justificasse essa circunstância, lembrando que sequer se conheciam anteriormente aos fatos.

Relevante mencionar que o réu Lucas, na fase policial, disse que as lesões que apresentava eram oriundas da fuga e não de agressões dos policiais, o que desmente a versão de que ele e o corréu teriam sido agredidos.

De outra parte, as testemunhas arroladas pelas defesas dos réus, Aparecida Silva e Rosimeire Manoel, ouvidas na fase judicial, não presenciaram os fatos, nada sabendo esclarecer sobre eles (fls. 284/285).

No que se refere aos entorpecentes, a perícia apontou que consistem realmente em "maconha" (exame químico-toxicológico de fls. 295/297).

Assim, a quantidade do entorpecente apreendido, ou seja, 1.006,4 gramas de maconha, as circunstâncias da abordagem dos réus (empreenderam fuga ao avistarem os policiais e reagiram à abordagem), a forma de acondicionamento das drogas (um tijolo de maconha), a apreensão do dinheiro, e a confissão informal aos policiais, estão a caracterizar a traficância.

Quanto ao dinheiro apreendido, o acusado não comprovou a sua versão apresentada no interrogatório judicial, inexistindo prova de que o valor apreendido seria de origem lícita, providência essa que seria de fácil consecução, caso fosse verdadeira a narrativa apresentada.

Ademais, a confirmar a prática do tráfico está a informação do próprio réu Lucas de que auferia, à época dos fatos, renda diária de R\$ 90,00 trabalhando na roça. Ora, exercendo esse trabalho, como é cediço, não é crível que conseguisse o réu adquirir, para uso próprio, a quantidade de cinco gramas de maconha (cada grama por R\$ 5,00) e cinco gramas de cocaína (cada grama por R\$ 10,00) totalizando R\$ 75,00 (sessenta e cinco reais) por dia e R\$ 2.250,00 (dois mil, duzentos e cinquenta reais) por mês, o que só vem confirmar a prática do tráfico.

Nunca é demais lembrar que é desnecessária a prova de ato de comércio, bastando que o agente traga consigo a droga para essa destinação, ainda que futura, na medida em que a consumação não exige qualquer resultado. Lembrando-se que os réus foram denunciados por trazerem consigo droga sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Portanto, a prova coletada nos autos é substancial e convincente, ficando evidente a autoria do crime por parte do réu, nos crimes ora apurados. Lembre-se que, no caso, não se exige o chamado "dolo específico", mas apenas o dolo genérico, restando evidente que o acusado praticava o tráfico de drogas.

Assim, além da robusta prova acima analisada, há indícios mais que suficientes para a prolação de decreto condenatório. Aliás, neste ponto, quanto ao crime de tráfico de drogas, tratando-se de delito, na maioria das vezes, praticado às escondidas, não se pode abrir mão dos indícios para o estabelecimento da verdade real. E a definição de indício vem estabelecida no próprio Código de Processo Penal, no artigo 239. Com isso, constata-se que o juiz formará a sua convicção na livre apreciação da prova, e, diante do nosso sistema processual, o indício é o fato provado que, por sua ligação íntima com o fato probando, autoriza a concluir algo sobre este, até porque os indícios estão inscritos no título da prova, e, assim, a autoria do delito, pelo sistema do livre convencimento, pode ser demonstrada, validamente, pela força probante dos indícios.

Sendo assim, não resta dúvida de que no dia, horário e local indicados na denúncia, os acusados traziam consigo 01 (um) tijolo de maconha, pesando 1.006,4 gramas, substância entorpecente, que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de entrega a consumo de terceiros.

A conduta dos réus encontra tipicidade na exata correspondência com o delito definido no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do

Código Penal.

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, exclua a culpabilidade dos denunciados ou extingam a punibilidade.

Resistência.

Quanto ao crime de resistência, a ação penal é improcedente e ambos os réus devem ser absolvidos.

Na delegacia e em juízo, o réu Márcio disse que foi ameaçado e agredido pelos policiais (fls. 07 e 284/285).

Lucas disse que as lesões que apresentava eram oriundas da fuga realizada por eles (fls. 09 e 284/285).

Os policiais Luiz Henrique Nogueira e Fernando Rodrigo Marchioli, ouvidos em ambas as fases da persecução penal, disseram que os acusados resistiram à prisão e entraram em luta corporal, sendo necessário uso de força física moderada (fls. 02, 03 e 284/285).

Pela prova existente nos autos, há indícios de que, na realidade, os acusados não se valeram de violência ou ameaça aos policiais responsáveis pelo cumprimento da ordem judicial.

A conduta dos acusados, portanto, vem a caracterizar a chamada resistência passiva, ou seja, o ato de espernear ou bravejar contra policial, ao ser preso, fato esse atípico (TACrSP, Julgados 66/345).

É essencial à configuração do crime de resistência que o agente use violência física ou ameaça contra os funcionários competentes para executar a ordem legal (STF, RTJ 106/494).

No caso, os acusados, ao que indica a prova oral produzida, não se valeram de violência física ou moral contra os policiais, mas dificultaram suas prisões, necessitando de uso de força física dos policiais para contê-los. Em suas atitudes, não se vislumbra intenção (dolo) de intimidar os agentes do Estado com violência ou ameaça, no intuito de não serem detidos.

Frise-se, não obstante a necessidade de utilização de força física dos policiais para conter o acusado, não há notícias nos autos de terem os policiais sofrido agressões físicas e ameaças, razão pela qual não há que se falar em crime de resistência.

Reconheço a ocorrência do delito e passo a aplicar as penas do crime de tráfico a ambos os réus, separadamente.

Das penas.

Réu Lucas.

O acusado não ostenta maus antecedentes, no entanto, nesta fase da aplicação da pena, deve ser levado em conta que a introdução de considerável quantidade de droga no mercado (nada menos do que 1.006,4 gramas de maconha, se fosse alcançada, traria efeitos altamente lesivos à sociedade. Evidente, assim, a necessidade de um maior rigor na fixação da pena-base, em patamar acima do mínimo legal, lembrando que seria absolutamente desprovido de razoabilidade apená-lo com a sanção base mínima, tratando-o igualmente, por exemplo, a quem fosse preso traficando algumas gramas daqueles entorpecentes.

Essa é a posição de nossos Tribunais:

“Na avaliação das circunstâncias legais para a fixação da pena, em se tratando de tráfico de entorpecentes, devem influir decisivamente a espécie e a quantidade da droga. O tipo de entorpecente é dado que indica o grau de nocividade para a saúde pública, correlato ao indicador das conseqüências do crime; a quantidade, quase sempre, aponta para o grau de envolvimento do infrator com o odioso comércio,

indicando a medida de sua personalidade perigosa e voltada para a prática criminosa" (STJ, HC 13.231-MS, 5ª T., j. 22.08.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 09.10.2000 - RT 786/599).

"Nos casos de tráfico de entorpecente, a fixação da pena obedecerá aos critérios do art. 59 do CP entre eles os motivos, as circunstância e conseqüências do crime, razão pela qual se admite a fixação de pena-base acima do mínimo legal, se houve apreensão de grande quantidade de droga" (STJ, HC 11.235-SP, 5ª T., j. 16.03.2000, rel. Min. José Arnaldo da Fonseca, DJU 17.04.2000, RT 783/594).

"Admissível, em tema de comércio clandestino de entorpecente, é a maior severidade na repreensão penal em face da natureza mais nociva ou da maior quantidade de substância tóxica apreendida" (TACRIM-SP-AC-Rel. Geraldo Pinheiro - JUTACRIM 44/293).

"A alta nocividade da cocaína está a exigir especial rigor no combate a seu tráfico, impondo-se, em conseqüência, a aplicação aos traficantes de reprimendas penais de severidade correspondente ao elevado risco que a nefanda mercancia acarreta à saúde pública" (TJRS - AC - 687055624 - Rel. Alberto de Moraes Lacerda - RJTJRS 130/154)

PENA - Agravantes - Tráfico de entorpecentes - Associação - Hipótese em que, se a Justiça Pública houvesse apelado, caberia modificação no decreto condenatório, pois a grande quantidade de entorpecente apreendida justificaria plenamente a aplicação da pena-base acima do mínimo legal, além de que o "modus operandi" do casal criminoso, demonstra organização que merecia maior rigor punitivo; todavia, como não é possível "reformatio in pejus", a pena cominada na r. sentença deve prevalecer - Preliminar rejeitada, recurso parcialmente provido. (Apelação Criminal n. 1.044.309-3/5 - São Paulo - 6ª Câmara Criminal - Relator: Marco Antonio - 23.8.2007 - V.U. - Voto n. 6.277).

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas.

Não é caso de reconhecimento da atenuante da confissão, porque, embora tenha o réu Lucas confessado a prática do tráfico na fase policial, acabou se retratando em juízo ao afirmar que a droga era somente para seu próprio consumo.

Na terceira fase, não vislumbro a existência de causas de aumento ou diminuição de pena. Quanto à causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, entendo não ser caso de sua incidência, porque restou demonstrado, por todos os elementos acima descritos, bem como pela apreensão de considerável quantidade de drogas (nada menos do que 1.006,4 gramas de maconha), que o acusado se dedicava à narcotraficância em escala expressiva, o que pressupõe uma relação de confiança entre as partes envolvidas, de modo que é forçoso reconhecer que se dedicava a atividade criminosa, fazendo do tráfico o seu meio de vida.

Em outros termos, a quantidade expressiva de entorpecente, inversamente ao princípio da insignificância, poderia causar conseqüências gravíssimas a um número imenso de pessoas, bem como denota periculosidade acentuada por parte do acusado, já que realizava o tráfico em larga escala, o que deve ser diferenciado do pequeno traficante, sob pena de violação do primado da igualdade, razão pela qual não faz "jus" à causa de diminuição de pena em questão.

Torno definitiva a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Réu Márcio.

O acusado não ostenta maus antecedentes, no entanto, a pena-base deve ser fixada acima do mínimo legal, em razão da quantidade da droga, como já exposto acima na fixação da pena do corréu Lucas.

Portanto, levando em conta o dado elencado, no aspecto acima relatado (quantidade da droga), fixo a pena-base acima do mínimo legal em 1/6 (um sexto), resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa.

Na segunda fase, reconheço a circunstância agravante da reincidência (fl. 337 - Proc. nº 0000042-93.2017.8.26.0603) razão pela qual elevo a pena em mais 1/6 (um sexto), resultando em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento ou de diminuição de pena a serem aplicadas. Não é caso de incidência da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, porque o réu é reincidente, o que afasta o benefício. Ademais, ainda que assim não fosse, também não seria o caso de aplicação dessa causa de diminuição, pelos mesmos motivos expostos na terceira fase da aplicação da pena do réu Lucas.

Torno definitiva a pena em 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no valor mínimo unitário (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06).

Diante da gravidade da conduta, mesmo levando-se em conta a detração penal disposta na Lei nº 12.736/12 (art. 2º, que acrescentou o § 2º ao art. 387 do CPP), as penas privativas de liberdade devem ser cumpridas no regime inicial fechado, obrigatoriamente, pois se trata de crime equiparado a hediondo, conforme estatuído no art. 2º, § 1º, da Lei nº 8.072/90.

Ademais, infere-se inviável, de igual sorte, a alteração do regime prisional, na hipótese, com esteio no lapso que perdurou a prisão cautelar, porque não se tem notícia a respeito da real situação carcerária dos acusados, isto é, se não registram outras condenações ou prisões processuais, nem quanto ao seu comportamento e conduta no cárcere, a revelar não existirem elementos seguros para a correta análise, nesta seara e de pronto, quanto a eventual direito à detração penal, emergindo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, à míngua de informações concretas.

O acusado Márcio deverá continuar a responder preso por este processo, pois assim permaneceu durante a instrução e ainda estão presentes os requisitos da custódia cautelar, como se verá doravante.

O acusado Lucas foi solto por ordem de habeas corpus e assim deverá continuar a responder ao processo, até o trânsito em julgado da presente.

Fica fixado cada dia-multa no valor mínimo unitário legal, diante a ausência de informações seguras sobre a capacidade econômica dos réus.

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal para:

1) ABSOLVER LUCAS GARCEZ URIAS E MÁRCIO DOS SANTOS MOTA da imputação que lhes foi feita na denúncia quanto ao crime do artigo 329, caput, do Código penal (resistência), com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal;

1) CONDENAR LUCAS GARCEZ URIAS, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do Código Penal;

2) CONDENAR MÁRCIO DOS SANTOS MOTA, qualificado nos autos, ao cumprimento das penas de 06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado (art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, com a redação da Lei nº 11.464/07), e pagamento de 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, no menor valor (art. 43, caput, da Lei nº 11.343/06), dando-o como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, nos moldes do artigo 29, do Código Penal.

Consigno que o réu Lucas ficou preso preventivamente desde 18/12/2020 até

05/02/2021 (fls. 185/187), e o réu Márcio está preso desde 18/12/2020 até a presente data, períodos sobre os quais fica reconhecida a detração penal, para fins de cumprimento do restante das penas, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei nº 12.736/12.

Deve, no entanto, a Serventia, ao expedir a Carta de Guia, atentar para se consignar a condenação total constante do dispositivo acima, com as observações consignadas no parágrafo anterior (detração penal).

Deixo de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, por entender incabível tal providência.

Não obstante o julgamento do Habeas Corpus n. 97.256, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual se entendeu por inconstitucional a vedação à substituição por penas restritivas de direitos para o crime de tráfico, por afronta ao princípio da individualização da pena, até então não se trata de decisão proferida com efeito erga omnes.

Foi editada a Resolução nº 5/2012, do Senado Federal, que, nos termos do artigo 52, inciso X, da Constituição Federal, suspendeu a execução de parte do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, que vedava de forma abstrata (sem análise do caso concreto) a conversão em penas restritivas de direito, declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo em decisão no Habeas Corpus já mencionado acima.

Com a mencionada Resolução, não se pode mais afirmar que o efeito do julgamento daquele habeas corpus não é para todos. Entretanto, a intenção do Supremo Tribunal Federal, ao decidir desta forma, e o Senado Federal, ao editar a resolução, foi somente deixar à prudente análise do magistrado do caso concreto se o réu tem ou não direito a ter a pena privativa de liberdade substituída por restritiva de direitos, e não que essa substituição seja admitida em qualquer caso de tráfico de drogas, indistintamente. Pensar assim seria um contra-senso.

Confira, neste sentido, decisão proferida em Apelação Criminal que analisou sentença proferida por este juízo:

"... Inviável, nesse passo, a pretendida substituição carcerária por restritivas de direito, porque, embora o teor da recente Resolução nº. 5/2012 do Senado Federal, fundada na decisão do Supremo Tribunal Federal proferida nos autos do Habeas Corpus, nº. 97.256/RS - mencionado nas razões recursais -, em controle difuso de constitucionalidade, in casu, permanece impossível, data vênua, a substituição prevista no artigo 44 do Código Penal, ou mesmo a concessão de sursis, pois o crime de tráfico de entorpecentes revela a gravidade peculiar que desestabiliza a vida em sociedade e fere de morte a saúde pública, pois enquanto fomenta, simultânea e irremediavelmente - até as pedras estão cansadas de saber -, a violência, a destruição de lares e das famílias e a prática de n crimes, sobretudo para o fim de viabilizá-lo, tanto assim que, por força de norma constitucional, é assemelhado aos delitos hediondos, cuja pena deve ser cumprida no regime prisional inicial fechado, determinação esta que se mostra incompatível com a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos ou com a suspensão condicional da pena, de modo que não se consegue compreender ou avaliar, por mais que se esforce, qual seria a pena substitutiva ou as condições do sursis adequadas ao traficante, emergindo sintomático que - até o momento - jurista sério algum tenha ousado sugeri-las..." (TJ-SP, Apelação Criminal nº 0009435-15.2010.8.26.0077, 5ª Câmara Criminal, rel. Des. Juvenal Duarte, j. 19.04.2012).

Ainda no mesmo sentido, confira julgamento proferido em processo que tramitou por essa comarca de Birigui:

"Também não faz jus a apelante à substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

A concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos condenados a tráfico de drogas é incompatível com a gravidade e as circunstâncias em que o crime é cometido, não havendo qualquer tipo de violação ao princípio da individualização da pena.

Este entendimento deve prevalecer, notadamente ao se considerar a vedação expressa trazida pelo artigo 44 da Lei de Drogas.

Com efeito, o benefício consistente na substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos tem por objetivo primordial o de possibilitar a ressocialização de indivíduos de baixa periculosidade, que praticaram delitos de pequeno grau de lesividade social.

Traficantes de substâncias entorpecentes, sejam de pequeno, médio ou grande porte, não tem o perfil de iniciar o cumprimento de sua pena que não mediante encarceramento. Mesmo o pequeno traficante merece uma punição severa. Basta que a venda de drogas seja realizada uma única vez, para que cause uma série de malefícios ao consumidor, as quais virão a repercutir a toda a coletividade. Ressalta-se que uma das exigências previstas no artigo 44, inciso III, do Código Penal, para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é a de que os motivos e as circunstâncias indiquem como suficiente tal medida, para a repressão do agente da conduta delituosa.

Conforme já fundamentado, tal benefício não se coaduna com as graves consequências que a mercancia de substâncias entorpecentes causa, não só ao usuário, com uma rápida deterioração da sua saúde física e mental, mas também ao corpo social (desestrutura familiar, estímulo à prática de outros crimes, como homicídios, latrocínios, extorsões etc.).

Muito embora o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do "Habeas Corpus" nº 97256/RS, tenha expressão "vedada a conversão em penas restritivas de direitos", contida no § 4º, do artigo 33, da Lei 11343/06, é de se ressaltar que tal decisão não possui o erga omnis.

E mesmo a resolução nº 5 do Senado Federal, de 15 de fevereiro de 2012, que suspendeu a eficácia da referida expressão, não acarreta direito subjetivo do agente que praticou o grave delito do tráfico de entorpecentes a tal conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

Frise-se, ainda, que o artigo 44 da Lei de Drogas mantém tal vedação ao crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput. Considerando que o § 4º é tão somente uma causa de diminuição do delito previsto no caput - e não um crime autônomo -, é possível concluir que a vedação a ele também se aplica.

Neste aspecto, ensina Guilherme de Souza Nucci que "(...) o fato de haver sido prevista uma causa de diminuição de pena para o traficante primário, de bons antecedentes, sem outras ligações criminosas, não afasta a tipificação da sua conduta como incursas no artigo 33, caput e § 1º, que são consideradas similares a infrações penais hediondas, como se pode observar pelas proibições enumeradas no artigo 44 da Lei 11343/06. Salienta-se, ademais, o cuidado legislativo em vedar a aplicação da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, típica opção de política criminal para o tráfico ilícito de drogas. Não se pode criar uma nova infração penal, a partir da mera aplicação de causa de diminuição de pena. Por isso, o tráfico ilícito de drogas será sempre considerado equiparado a hediondo, ainda que comporte, por opção legislativa, pena mais branda, quando os requisitos do § 4º estiverem presentes" (in "Leis Penais e Processuais Penais Comentadas", 5ª ed., São Paulo, Revista dos Tribunais, 2010, p.372).

Desta forma, NEGOU PROVIMENTO ao recurso, mantendo, integralmente, a respeitável sentença de primeiro grau" (Apelação Criminal nº 0002364-20.2014.8.26.0077. Rel. Toloza Neto).

Não bastassem esses argumentos, as penas fixadas ultrapassam quatro anos e o acusado Márcio é reincidente, o que também afasta a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afora isso, o réu Márcio é reincidente específico, o que afasta também a aplicação do § 3º do artigo 44 do Código Penal. Não bastasse isso, para ambos os réus, a substituição ainda não seria suficiente nem socialmente recomendável, em razão da grande quantidade de droga apreendida, não preenchendo, também, o requisito do artigo 44, inciso III, do Código Penal. O acusado Márcio deverá continuar a responder preso a este processo, eis que sua prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva, conforme decisão proferida às fls. 66/70, a cujos fundamentos me reporto, como razão de decidir, bem como

aqueles expostos na decisão de fls. 153/154, que indeferiu pedido de liberdade provisória.

Ademais, continuam presentes os requisitos que recomendam a custódia cautelar do acusado, mormente porque praticou delito equiparado aos hediondos. Afora isso, o acusado Márcio é reincidente em crime doloso, razão pela qual a ordem pública merece resguardo.

Recomende-se o réu Márcio na prisão em que se encontra, com fundamento nos artigos 59 da Lei nº 11.343/06, c.c. o § 4º do artigo 2º da Lei nº 8.072/90, acrescentado pela Lei nº 11.464/07.

Por fim, em atenção ao disposto no artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, após 85 (oitenta e cinco) dias contados da publicação da sentença, tornem os autos conclusos para revisão da necessidade de manutenção ou não da decisão que manteve a prisão preventiva, mantendo-se os autos na fila "acompanhamento de prisão preventiva".

O réu Lucas poderá continuar a responder solto a este processo, até o trânsito em julgado, pois assim permaneceu após a concessão da ordem em habeas corpus (fl. 177).

Com relação ao dinheiro encontrado com um dos acusados (R\$ 30,00), apreendido às fls. 12/13 e depositado à fl. 108, como não houve prova da sua procedência lícita, não há como se deixar de reconhecer que é produto do tráfico de entorpecentes por ele praticado, razão pela qual, com fundamento nos artigos 91, inciso II, alínea "b", do Código Penal, e 63 da Lei nº. 11.343/06, decreto o perdimento do dinheiro (R\$ 30,00).

Da mesma forma, fica decretada a perda da motocicleta apreendida à fls. 12/13, por ser instrumento do crime de tráfico de drogas praticado pelos réus.

Após o trânsito em julgado, comunique-se o "Senad" quanto ao perdimento supradeterminado (dinheiro e moto), instruindo o ofício com cópias do auto de exibição e apreensão, da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Após o trânsito em julgado, oficie-se também à Delegacia de Polícia de origem, informando sobre o perdimento do dinheiro (R\$ 30,00) e da moto (fls. 12/13), e, instruindo-se o ofício com as cópias.

A incineração dos entorpecentes apreendidos já foi determinada (fls. 66/70) e realizada (fls. 217 e 223), nada mais havendo a ser decidido a respeito.

Com o trânsito em julgado da presente, oficie-se ao Cartório Eleitoral, nos termos do artigo 28 da Resolução nº 23.399/13 do TSE, instruindo o ofício com cópias da presente sentença e eventual Acórdão, bem como das certidões de trânsito em julgado para as partes.

Custas, na forma da lei.

P. R. I.

Birigui, 26 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA